

0000816-03.2021.8.26.0242

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... de DIONATAN em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, e absolvição em relação ao delito de associação ao tráfico, bem como absolvição de ANTÔNIO MARCOS em relação ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, tecendo considerações em cada uma das etapas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo n.0000816-03.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000816-03.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra DIONATAN MOREIRA DA FONSECA e ANTÔNIO MARCOS GOMES FILHO, qualificados nos autos (fls. 45 e 43/44, respectivamente), pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do artigo 69, do Código Penal e artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, respectivamente.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva (fls. 61/69).

Posteriormente, a prisão preventiva de Antônio foi revogada (fls. 181/183) e o alvará de soltura devidamente cumprido (fls. 187/188).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021, conforme decisão de fls. 248/250.

Os pedido de arquivamento em relação ao coinvestigado Reginaldo (fls. 242/243, item 4) foi acolhido (fls. 249).

Os réus foram citados (fls. 262/263 e 274/275) e apresentaram defesa preliminar (fls. 264/265 e 282/283).

A instrução foi realizada por videoconferência, ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e dois informantes do Juízo, bem como realizado o interrogatório dos acusados (fls. 326/328).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento parcial da pretensão punitiva deduzida na denúncia, com a condenação de DIONATAN em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, e absolvição em relação ao delito de associação ao tráfico, bem como absolvição de ANTÔNIO MARCOS em relação ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, tecendo considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena, além de requerer a remessa de cópias à autoridade policial para reabertura do inquérito e reinício de investigações em face de Reginaldo (fls. 329/333).

A Defesa Técnica do acusado ANTÔNIO MARCOS, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu por ausência de provas (fls. 334/335).

A Defesa Técnica do acusado DIONATAN, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu dos crimes a ele imputados em razão da ausência de provas de materialidade e autoria, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma (fls. 336/345).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Em sede prejudicial ao mérito, verifico que a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público aos fatos narrados na denúncia merece reparo.

Apesar de a inicial acusatória imputar a prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ao acusado (artigo 16, §1º, IV, Lei n. 10.826/03), em relação à apreensão da arma de pressão adaptada para o calibre 22, trata-se de crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, Lei n. 10.826/03)

Além de o laudo pericial acostado às fls. 171/174 não constatar eventual numeração suprimida ou adulterada, considerando-se que armas de calibre 22 são de uso permitido, nos termos do artigo 3º, inciso I, do Decreto Federal n. 10.030/2019, e Portaria n. 1.222/2019 (Anexo A) do Ministério da Defesa, entendo que o caso se amolda ao tipo penal previsto no artigo 14, da Lei Federal n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Ressalto que a classificação jurídica dada ao fato na denúncia não vincula o julgador, pois, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, ela poderá ser modificada, desde que não haja alteração da descrição do fato contido na denúncia ou queixa, ainda que, conseqüentemente, tenha de ser aplicada pena mais grave.

Dispõe o referido dispositivo que: “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à Defesa, motivo pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, eis que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial. Nesse sentido, STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 01.06.06, DJ de 01.08.06.

Assim sendo, em atenção ao princípio da correlação (a sentença deve ser o espelho da imputação fática realizada pelo órgão acusatório) e ao que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, atribuo definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia para que passem a ser analisados como crimes tipificados no artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Passo a analisar o mérito.

Os réus DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS e ANTÔNIO MARCOS GOMES FILHOS foram denunciados porque, supostamente, em data, local e horário não sabidos, antes do dia 06 de setembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Igarapava/SP, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta ainda que, supostamente, no dia 06 de setembro de 2021, às 22h20, na Avenida Mogiana, n. 3.380, Alto do Igati, nesta cidade e Comarca de Igarapava, os dois

acusados guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, pesando 15,12g (quinze gramas e doze centigramas), e 07 (sete) porções de maconha, pesando 10,06g (dez gramas e seis centigramas). Consta, por fim que, supostamente, de data incerta até o dia 06 de setembro de 2021, por volta das 22h20, na Avenida Mogiana, n. 3.380, Alto do Igati, nesta cidade e Comarca de Igarapava, o acusado DIONATAN, com consciência e vontade, possuía, no interior da residência, arma de fogo com numeração suprimida e munições.

Após regular instrução probatória, entendo que a pretensão acusatória merece ser acolhida em parte.

I) Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06:

A materialidade do crime de tráfico foi evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo laudo de constatação provisória (fls. 25/27), pelo Boletim de Ocorrência n. 651/2021 (fls. 28/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/35), pelo laudo pericial químico toxicológico (fls. 190/192), pelo relatório final (fls. 201/204), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. A autoria do delito, em relação ao acusado DIONATAN, também foi comprovada. Por outro lado, os indícios de autoria relacionados ao acusado ANTÔNIO MARCOS não são suficientes para sua condenação.

A testemunha de acusação Bruno Faria Abrão Lúcio, policial militar, disse, em Juízo, que receberam notícias de que Reginaldo (vulgo "Garapa") teve um desentendimento com populares em via pública, e, posteriormente, de que Reginaldo efetuou disparos de arma de fogo na referida via. Contou que sua equipe se dirigiu às proximidades, pediu apoio da outra viatura e enquanto aguardavam o reforço foi possível ouvir 3 (três) estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Narrou que, com a chegada da outra equipe, deslocaram-se ao local e, ao acessar a via, foi possível visualizar algumas pessoas em frente à residência informada, momento em que ouviu um novo disparo de arma de fogo. Disse que se aproximaram dos indivíduos, ao que Reginaldo entregou algum objeto nas mãos de pessoa desconhecida que saiu correndo ao avistar a viatura. Descreveu que realizaram a revista de Reginaldo em via pública e no interior da residência foi possível visualizar DIONATAN com um objeto nas mãos, momento em que foi dada ordem para levantar as mãos, ao que ele se deitou no chão. Disse que o objeto que se encontrava com ele foi deixado no sofá e identificado como uma pistola de pressão adaptada para o calibre 22, sendo que no interior do cano havia uma munição deflagrada de calibre 22. Contou que após conter DIONATAN foi possível visualizar em cima da pia uma caixa com determinada quantidade de maconha e dinheiro. Contou que prosseguiram nas buscas e em cômodo ao lado da pia foram localizadas mais drogas, objetos para separação do entorpecente e quantia em dinheiro. Descreveu que com ele também foi localizada uma quantia em dinheiro no valor de R\$ 107,00 (cento e sete reais). Disse que foi dada voz de prisão a eles e conduzidos à Delegacia. Esclareceu que Reginaldo se identificou como o responsável pela casa e DIONATAN não soube explicar o motivo pelo qual estava no imóvel. Em relação a ANTÔNIO, disse que não foi encontrado nada de ilícito, apenas um aparelho celular e ele teria dito que parou no imóvel para conversar. Disse que existem notícias de que Reginaldo e DIONATAN são vinculados ao tráfico de drogas e já foram abordados anteriormente em razão desse suposto envolvimento. Em relação a ANTÔNIO, disse não saber informar acerca de suposto envolvimento com tráfico e não se recorda de tê-lo abordado. Narrou que a Avenida Mogiana é um local conhecido na Comarca pelo tráfico de entorpecentes (fls. 326/328 - mídia digital).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Fábio de Oliveira Sales, o qual afirmou que no dia dos fatos receberam ligação via 190 informando que Reginaldo "Garapa" estava na localidade portando arma de fogo. Mencionou que posteriormente receberam outra ligação informando que o mesmo indivíduo efetuou disparos pela via. Narrou que se deslocaram pelas proximidades do local e ouviram 3 (três) disparos vindo daquela localidade, ocasião em que solicitaram o apoio de outra viatura. Disse que, ao adentrar na via, escutaram outro disparo e, por esse local,

visualizaram Reginaldo entregar algo a uma pessoa desconhecida, que evadiu-se a pé ao visualizar a viatura. Contou que, ao abordar Reginaldo, visualizaram DIONATAN dentro do imóvel portando objeto semelhante a arma de fogo, sendo ordenado que colocasse as mãos na cabeça, ao que jogou o objeto em um sofá próximo. Narrou que foi realizada a abordagem, sendo encontrados R\$ 107,00 (cento e sete reais) em dinheiro em seu bolso. Afirmou que, ao lado, encontrava-se ANTÔNIO, sendo encontrado apenas um celular com ele. Declarou que visualizaram uma caixa pequena próxima a DIONATAN, contendo certa quantidade em dinheiro e, dentro, uma certa quantidade de maconha já embalada para venda. Disse que efetuaram buscas em outro cômodo do local, achando dentro de um prato aproximadamente 15g (quinze gramas) de crack, que estavam sendo fracionadas com uma lâmina. Contou que, durante a busca à suposta arma de fogo, também foi encontrada uma munição deflagrada, bem como 2 (duas) munições intactas. Declarou que foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos ao distrito policial. Disse que DIONATAN e Reginaldo são conhecidos dos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, bem como o local onde se deu a ocorrência. Esclareceu que, embora em quantidade bem menor, já teve notícias do envolvimento de ANTÔNIO com a prática de tráfico de drogas. Afirmou que DIONATAN assumiu a propriedade das drogas localizadas e ninguém assumiu a propriedade do artefato encontrado, em que pese tenham visto ele jogando ela no sofá. Esclareceu que Reginaldo manteve-se em silêncio e ANTÔNIO disse que morava no local, mas não fazia traficância. Disse que a casa sempre foi um local de comércio de drogas e não sabe precisar o proprietário. Questionado acerca da informação de que ANTÔNIO moraria próximo ao local, na Avenida Mogiana, n. 3458, e teria ido até lá encontrar "Garapa" e DIONATAN, reafirmou que fez sua abordagem e ANTÔNIO disse que morava no imóvel. Esclareceu que estavam em 4 (quatro) policiais e que, em dado momento, estavam em outro cômodo, mas, a princípio, todos permaneceram juntos. Disse que não percebeu nenhuma dificuldade de ANTÔNIO em manifestar as próprias ideias. Declarou que, anteriormente, a casa era um bar e fica ao lado de um bar, desconhecendo ser de propriedade de Thamires. Negou que os policiais tenham tentado levar Thamires para o interior do imóvel. Esclareceu que ANTÔNIO estava dentro da casa quando chegaram e Reginaldo e o indivíduo que evadiu-se estavam de fora da casa, enquanto os vizinhos estavam ao lado (fls. 326/328 - mídia digital). Registro que tanto na fase investigativa (fls. 05/06) quanto na etapa judicial os depoimentos dos policiais revelaram-se coesos e harmônicos, uma vez que as circunstâncias fáticas foram descritas em detalhes, sendo descritas, ainda, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo no imóvel, aspectos que foram corroborados pelo auto de exibição e apreensão e laudos acostados nos autos. A jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96). Neste sentido, segundo o E. TJSP: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017). Não há nos autos qualquer prova de que os policiais tinham agido com a intenção de prejudicar os acusados, já que os réus não levantaram qualquer suspeita sobre as declarações dos agentes. Nesse sentido, acusados e Defesas Técnicas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais testemunhos.

A informante Thamires de Jesus Silva relatou que ANTÔNIO MARCOS estava conversando com ela e pediu um guaraná, dando-lhe R\$ 5,00 (cinco reais), ao que buscou o refrigerante e sentou-se na cadeira, enquanto ele permaneceu de pé ao seu lado conversando, momento em que a viatura chegou e o puxou para dentro da casa. Afirmou que ele não estava dentro da casa, apenas Reginaldo e DIONATAN, não sabendo precisar se estavam lá antes ou depois dos policiais chegarem. Esclareceu que estava na calçada de sua casa, que fica ao lado do imóvel. Declarou que DIONATAN e Reginaldo ficavam na casa na época dos fatos, mas nenhum morava lá, não possuindo conhecimento do envolvimento deles com tráfico de drogas, tampouco sabendo explicar as drogas encontradas no local. Disse que não tem conhecimento do envolvimento de ANTÔNIO com tráfico ou uso de entorpecentes. Esclareceu que conhece DIONATAN e ANTÔNIO faz 3 (três) anos, tempo em que mora na Avenida Mogiana, n. 3329, local em que sua mãe Gorete possui um bar, auxiliando-a nos trabalhos. Negou ter ouvido ou visto disparos de arma de fogo no dia dos fatos. Disse que Reginaldo e DIONATAN não são amigos, tampouco ANTÔNIO. Disse que ANTÔNIO e DIONATAN moram na Avenida Mogiana e nunca foi na casa ao lado. Questionada acerca das atividades de DIONATAN e Reginaldo no imóvel, apesar de não morarem lá, disse desconhecer o que eles faziam no local e não conhecer mais ninguém que ficasse no local. Mencionou que um dos policiais tentou puxá-la para dentro da casa e disse que não iria entrar pois estava na porta de sua casa, ocasião em que ele teria puxado ANTÔNIO para dentro do imóvel. Disse não ter conhecimento de quem seria o proprietário da casa. Disse que ANTÔNIO e DIONATAN trabalham, este último como servente de pedreiro com o padraço. Esclarece conhecer mais a família de DIONATAN, não tendo intimidade com ele (fls. 326/328 - mídia digital).

A testemunha de defesa Donizete Diogo de Souza disse que mora na Avenida Mogiana e estava na porta de sua casa no dia dos fatos. Afirmou que não ouviu disparos de arma de fogo no dia e não sabe quem estava na casa quando os policiais chegarem. Disse que conhece DIONATAN e ANTÔNIO há uns 15 (quinze) anos, não tendo conhecimento do envolvimento deles com tráfico de drogas, apenas com relação a Reginaldo. Afirmou que ANTÔNIO estava no bar em frente ao local dos fatos, onde parou para conversar com a moça e tomar um guaraná, momento que a polícia chegou, o pegou e jogou para dentro da casa. Disse que os policiais tentaram levar a moça para dentro da casa também. Esclareceu que ANTÔNIO mora cerca de 5 (cinco) ou 6 (seis) casas pra frente do imóvel onde os fatos ocorreram, disse que ele sempre trabalhou e apresenta raciocínio mais lento. Afirmou que a casa é de propriedade do "Garapa", que via DIONATAN de vez em quando lá, mas ele não morava lá, apenas Reginaldo. Disse que nunca viu ANTÔNIO na casa (fls. 326/328 - mídia digital).

Isabel Cristina Gomes, informante do Juízo, disse que não presenciou os fatos, apenas foi informada do que estava acontecendo, mas quando chegou ao local os policiais já tinham levado ANTÔNIO para a Delegacia. Declarou que é tia de ANTÔNIO e cuida dele desde criança, ressaltando que teve uma infância complicada, com vários problemas devido ao déficit de atenção, passando por psicólogo e psiquiatra e tomando remédio por muitos anos e que até hoje apresenta dificuldades. Afirmou que ANTÔNIO estava trabalhando com seu esposo em um sítio das 07h00 (sete horas) até as 12h00 (doze horas) ou 17h00 (dezessete horas) e que ele, atualmente, conseguiu emprego como operador de roçadeira na pista. Disse que ANTÔNIO não tem envolvimento com drogas. Declarou que não conhece DIONATAN, apenas o vê na rua, mas não tem contato nem amizade. Afirmou que mora na Avenida Mogiana e foi informada de que Reginaldo e DIONATAN moravam na casa, não tendo conhecimento de suas atividades no local (fls. 326/328 - mídia digital).

Interrogado em juízo, o acusado DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS declarou que apenas fazia uso de drogas no local e não encostou na arma. Disse que a casa do Reginaldo fica em frente a sua casa e frequentava o imóvel de vez em quando para fazer uso de entorpecentes. Negou o tráfico de drogas com Reginaldo. Disse que trabalha como servente de pedreiro com seu avô e o fato foi num domingo, ocasião em que tinha recebido o dinheiro dele por dois dias de serviço (quinta e sexta).

Relatou que estava dentro da residência fazendo uso de drogas, viu Reginaldo sair, efetuar um disparo e colocar a arma em cima do sofá, sendo posteriormente apreendida pelos policiais. Disse que conhece Reginaldo faz anos, que a casa é dele

e que a arma estava na posse dele. Esclareceu que toda a droga encontrada no local, tanto crack quanto a maconha, era sua, para usar. Questionado, disse desconhecer a existência de gilettes e sacos plásticos no local, sabendo que tinha várias latas para "fumar pedra" e bitucas de cigarro no local. Reafirmou que toda a droga encontrada era de sua propriedade, destinada a uso. Disse que havia 3 (três) porções de crack e 4 (quatro) porções de maconha, compradas na Rua da Lama, do outro lado da cidade, não sabendo dizer com quem comprou. Disse que pagou R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no crack e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) na maconha. Disse que ganha R\$ 300,00 (trezentos reais) por semana como servente de pedreiro, mas trabalhou só 2 (dois) dias e que seu avô lhe pagou um dia a mais, adiantado, para trabalhar na segunda. Disse que recebe entre R\$ 70,00 (setenta reais) e R\$ 80,00 (oitenta reais) por dia de serviço, a depender do trabalho. Esclareceu que, antes da polícia chegar, estava dentro da casa usando drogas, pois o local era um ponto de comércio antigamente e como Reginaldo mora lá e mobiliou o local, fazia uso de drogas no imóvel já que Reginaldo também é usuário. Disse que ficou o tempo todo dentro da residência (fls. 326/328 - mídia digital).

Já o acusado ANTÔNIO MARCOS GOMES FILHO, em juízo, declarou que não se recorda dos fatos. Disse que estava no bar comprando um guaraná, conversando com Thamires e que não viu os policiais chegando por trás dele. Afirmou conhecer "de longe" DIONATAN e Reginaldo e que a casa pertence à Reginaldo. Disse que DIONATAN não ficava no local, não sabendo dizer por que ele estava na casa no momento dos fatos.

Esclareceu que trabalhava na "roça" e chegava só à noite em casa. Questionado acerca do depoimento em fase policial, ocasião em que estava acompanhado de advogado (fls. 07) e disse "(...) Que parou no local para conversar com seus conhecidos Dionatan e "Garapa", vez que eles residem no local, ocasião em que foi surpreendido pela abordagem dos policiais militares (...)", disse não se recorda de dizer isso e narrou que estava conversando com Thamires, que foi pegar um guaraná, momento em que DIONATAN conversou com ele neste intervalo. Disse que não tem conhecimento acerca do proprietário das drogas e da arma encontradas no imóvel, não sabe se DIONATAN e Reginaldo vendem drogas na casa e não viu ou escutou disparos de arma de fogo antes da chegada dos policiais. Afirmou que mora há cerca de 8 (oito) metros do local, umas 5 (cinco) ou 6 (seis) casas para frente e disse que, desde então, a casa está fechada, sem morador. Questionado acerca do interrogatório de DIONATAN, que disse que permaneceu dentro do imóvel o tempo todo, disse que estava conversando com DIONATAN enquanto Thamires buscava o guaraná, bem antes da chegada da polícia, e depois ele entrou no imóvel e ele continuou aguardando o guaraná. Declarou que conversou com DIONATAN sobre sua namorada, pois estava voltando da casa dela e DIONATAN não usou drogas enquanto conversavam. Disse que o bar e a casa são colados um no outro e não dava para ver da rua o que estava acontecendo dentro da casa. Disse que "Garapa" estava dentro da casa, mas não conversou com ele (fls. 326/328 - mídia digital).

Registro que, em sede policial, o réu Antônio Marcos disse "(...) Que parou no local para conversar com seus conhecidos Dionatan e "Garapa", vez que eles residem no local, ocasião em que foi surpreendido pela abordagem dos policiais militares. Que não tem conhecimento que o local é ponto de tráfico de drogas. Que o interrogando não é usuário, nem traficante de drogas, sendo que parou no local apenas para conversar com seus conhecidos. Que não viu, nem ouviu disparo de arma de fogo no local. Que no momento da abordagem estava conversando com o Dionatan na calçada. Que entrou no bar para comprar um refrigerante que é ao lado da casa do Dionatan." (fls. 07/08).

Entendo que a autodefesa apresentada pelo acusado DIONATAN mostrou-se evasiva e isolada nos autos, estratégia última adotada por ele no intuito de ver afastado o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelo delito cometido.

Como se vê, DIONATAN alegou que estava dentro da residência de Reginaldo para utilizar entorpecentes, mas admitiu a propriedade da droga encontrada no imóvel. Ademais, conforme narrado pelos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, DIONATAN estava com objeto em mão e o deixou no sofá, sendo que tal objeto foi identificado como sendo uma arma de pressão adaptada para munição calibre 22, com uma munição deflagrada.

Além disto, no imóvel, os policiais militares disseram ter encontrado na pia uma caixa preta contendo sete porções de "maconha" e onze reais em dinheiro, sendo que no cômodo ao lado encontrou dentro de um prato três porções embaladas da substância conhecida como crack, três lâminas e fragmentos de crack prontos para uso, drogas cuja propriedade foi admitida pelo réu DIONATAN.

Os policiais localizaram ainda um recipiente de vidro contendo R\$36,00 em moedas, sessenta e um saquinhos plásticos comumente usados para acondicionar drogas para venda, um recipiente de fermento em pó, contendo pó branco, geralmente utilizado para misturar a droga, um pires e duas munições calibre 22, intactas. Com Reginaldo foi encontrada a quantia de R\$90,00 em notas diversas e com DIONATAN a quantia de R\$ 107,00 (cento e sete reais) em notas diversas.

Ressalto que a localidade é notoriamente conhecida na Comarca como ponto de comércio ilícito de entorpecentes e que o próprio imóvel foi descrito como ponto de tráfico de drogas, aspecto que pode ser deduzido, inclusive, pelo interrogatório judicial de DIONATAN no momento em que ele afirma que "lá era um ponto de comércio antigamente e como Reginaldo mora lá e mobiliou o local, a gente fazia uso de drogas lá - sic").

Acrescento que, em que pese a casa aparentemente pertença a Reginaldo, as oitivas realizadas em juízo permitem concluir que DIONATAN frequentava o imóvel em conjunto com o próprio Reginaldo, de forma assídua, conforme apontado pela a informante Thamires, vizinha da casa, pela testemunha Donizete e pela informante Isabel. Inclusive, no momento dos fatos, Reginaldo estava na rua e DIONATAN permanecia dentro do imóvel.

Reitero que, foram encontrados, conforme boletim de ocorrência de fls. 28/32 e auto de exibição e apreensão de fls. 33/35: a) com o acusado DIONATAN, R\$107,00 (cento e sete reais) em notas diversas em seu bolso; b) na pia próxima a ele, uma caixa preta, aberta, contendo 07 (sete) porções de maconha e R\$ 11,00 (onze reais) em dinheiro; c) no cômodo ao lado, um prato com 03 (três) porções de crack embaladas e fragmentos prontos para uso, 1 (uma) lâmina de barbear da marca Wilkison e 2 (duas) lâminas de estilete, um recipiente de vidro com R\$ 36,20 (trinta e seis reais e vinte centavos) em moedas, 61 (sessenta e uma) embalagens de plástico transparentes "sacolé", utilizados para embalar drogas para venda, e um recipiente de fermento em pó, contendo pó branco, geralmente usado para misturar a droga.

As substâncias entorpecentes encontradas estavam fracionadas e embaladas de forma individualizada (07 porções de maconha e 04 porções de crack, sendo apenas 01 pronta para uso), as quais foram devidamente constatadas, conforme laudos periciais de fls. 25/27 e 190/192, cujo resultado foi positivo para maconha e cocaína (substância base do crack), o que foi corroborado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/35). Registro que o conteúdo da embalagem de fermento em pó restou negativo para substâncias entorpecentes, nos termos dos laudos periciais já citados.

Destaco que DIONATAN já foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (fl 353).

Assim, analisando detidamente os autos, está satisfatoriamente comprovado o envolvimento do acusado DIONATAN com o tráfico de drogas.

Na contramão do que alega a Defesa Técnica, não há que se falar em ausência de provas aptas e seguras da existência do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, não sendo então o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Acrescento, ainda, que a alegação do réu de que é usuário, por si só, não exclui a traficância, ainda mais quando são contundentes as provas produzidas nos autos em relação crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, como requerido pela Defesa.

Esclareço que o tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 é do

tipo misto alternativo. É dizer, em palavras simples, que existem vários verbos que implicam na prática da narcotraficância. O acusado respondeu pelo ter em depósito, consumando-se o delito no momento em que foram encontradas e apreendidas 07 (sete) porções de maconha (10,06g) e 04 (quatro) porções de crack (15,12g).

Consigno que é tranquila a posição do E. TJSP acerca da desnecessidade de que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Ademais, esclareço que, embora a quantidade de maconha e crack e apreendidas tenha sido pequena, é certo que os demais elementos de prova demonstram, sem sombra de dúvidas, a ocorrência do tráfico de drogas praticado pelo acusado. Além disto, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que até mesmo "a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (...)". (STJ, HC 131.455/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 15/08/2012).

De fato, a narcotraficância foi evidenciada por significativos elementos informativos e probatórios, arrolados a seguir:

Pela diversidade, natureza e forma em que embaladas as substâncias entorpecentes - 7 porções de maconha (10,06g - dez gramas e seis centigramas) no interior de caixa em conjunto com R\$ 11,00 (onze reais) em dinheiro e 04 (quatro) porções de crack (15,12g - quinze gramas e doze centigramas), sendo 03 (três) embaladas em segmentos plásticos e 01 (uma) pronta para uso, conforme laudo de constatação provisória (fls. 25/27);

Existência de demais objetos relacionados ao crime de tráfico, tais como 3 lâminas para preparo e separação da droga e 61 sacos plásticos para acondicionamento do entorpecente;

Resultado positivo do laudo químico toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 190/192);

Os firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase investigativa como em Juízo, os quais corroboraram a narrativa descrita na inicial acusatória no sentido que o réu tinha em depósito entorpecentes para fins de tráfico;

O local da apreensão dos entorpecentes (residência localizada na Avenida Mogiana) é notoriamente conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas nesta Comarca;

O próprio réu DIONATAN admitiu a propriedade da droga.

Pelas demais circunstâncias da prisão em flagrante e provas acostadas aos autos.

Tais elementos de prova, analisados em conjunto, demonstram, sem sombra de dúvida, a existência do crime de tráfico de drogas imputado ao réu DIONATAN.

Portanto, em meio a este cenário probatório, conclui-se que a prova quanto à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas é segura e incriminatória, razão pela qual se faz necessária a responsabilização penal do acusado DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS, nos termos do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06.

Por outro lado, em relação ao acusado ANTÔNIO, não existem elementos seguros de que ele praticava o tráfico de entorpecentes.

Embora ANTÔNIO estivesse no local destinado à prática do crime de tráfico de drogas, não foram colhidos elementos de prova específicos sobre a conduta desenvolvida pelo réu em questão.

Neste sentido, verifico que ao lavrar o auto de prisão em flagrante, a Autoridade Policial cuidou de minudenciar aspectos relativos às condutas e vida pregressa dos averiguados DIONATAN e REGINALDO (vulgo "Garapa"), sendo que, por outro lado, referida Autoridade nada mencionou particularmente sobre ANTONIO MARCOS, de modo que, com exceção ao fato de estar no local quando da realização da abordagem policial, inexistem nos presentes autos dados concretos relacionados à conduta

deste investigado que se amolde aos crimes apurados.

Do mesmo modo, acrescento que os depoimentos dos policiais militares em relação a ANTONIO MARCOS limitaram-se a considerar que ele estava no local dos fatos e também foi abordado, sem que menção a demais particularidades sobre o suposto envolvimento de tal autuado quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ressalto que nada de ilícito foi encontrado com o referido réu.

Além disto, ao contrário de DIONATAN e REGINALDO, ANTONIO MARCOS é primário e não ostenta nenhum registro criminal em sua folha de Antecedentes.

Acrescento ainda que o réu DIONATAN assumiu a propriedade de toda a droga encontrada no imóvel.

Desta forma, concluo que não são seguros os elementos de autoria em relação a ANTONIO MARCOS, de modo que deve ser absolvido.

Consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, "se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 6.^a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 656).

Nesse sentido:

"Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio in dubio pro reo" (STJ - REsp. 171.995-DF - Rel. Min. Edson Vidigal - 5.^a T. - j. 21.09.99).

"Não provada a existência dos fatos narrados na peça acusatória, impõe-se a improcedência da denúncia" (STJ - APn. 183-0-ES - Rel. Min. Huberto Gomes de Barros - C. Esp. - j. 03.08.2005).

Nessas condições, não havendo segurança sobre a autoria do crime de tráfico atribuído ao acusado Antônio Marcos Gomes Filho, de rigor sua absolvição, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional do in dubio pro reo e da presunção de inocência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II) Do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06):

No que se refere ao crime de associação para o tráfico, não existem provas seguras em relação ao estabelecimento de vínculo associativo estável e permanente entre os réus.

Não existem provas sobre o vínculo associativo entre ANTÔNIO MARCOS e DIONATAN, e, embora existam indícios de ligação entre este e Reginaldo, não se comprovou cabalmente que estariam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, sendo seguras as provas apenas em relação ao crime de tráfico praticado pelo réu DIONATAN.

Neste sentido, os entorpecentes apreendidos no local quando da prisão em flagrante são insuficientes para sustentar, por si só, a existência do crime do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, reclamando-se maior amplitude probatória que concretamente fosse capaz de demonstrar a estabilidade e permanência da associação, o que não ocorreu no deslinde da ação penal, sobretudo porque os fatos são derivados de prisão em flagrante, e não de anterior e detalhada investigação, que, em tese, poderia ser capaz de estabelecer tal vínculo associativo.

Logo, os acusados devem ser absolvidos em relação a este delito, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III) Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003):

Este delito foi imputado apenas em relação a DIONATAN.

Tal pretensão acusatória deve ser acolhida

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo foi evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência n. 651/2021 (fls. 28/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/35), pelo laudo pericial (fls. 171/174), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

De igual modo, a autoria em relação ao acusado DIONATAN também foi demonstrada.

Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e evidenciam com segurança que o réu portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado, a Polícia Militar foi acionada ante a informação de que Reginaldo teria efetuado disparos de arma de fogo na via pública, ao passo em que os policiais que atenderam a ocorrência ouviram outros 3 (três) disparos enquanto aguardavam o reforço e ouviram um último disparo no momento em que acessaram a via. Segundo relatado, Reginaldo entregou algum objeto para desconhecido que não foi localizado, sendo abordado defronte à residência, momento em que os agentes de segurança pública visualizaram DIONATAN dentro do imóvel, de posse de um objeto, ocasião em que foi ordenado que colocasse aos mãos à cabeça, ao que ele dispensou o mencionado item em um sofá próximo. Após ingressar no imóvel, os policiais constataram que tratava-se, de fato, da arma de pressão adaptada apreendida (fls. 34).

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime e disse que estava fazendo uso de entorpecentes no imóvel, quando Reginaldo saiu, efetuou o disparo e colocou a arma em cima do sofá.

Tal versão, evasiva e isolada nos autos, estratégia última adotada por ele no intuito de ver afastado o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelo delito cometido, não resiste ao confronto com os depoimentos dos policiais militares, conforme já exposto anteriormente, que narraram, com riqueza de detalhes, que Reginaldo, antes de ser abordado do lado de fora do imóvel, entregou objeto desconhecido para terceiro que fugiu, momento em que visualizaram DIONATAN dentro do imóvel com um objeto e deram o comando para que erguesse as mãos. Além do mais, importante registrar, como já dito na análise do crime de tráfico de entorpecentes, que, em que pese a casa aparentemente pertença a Reginaldo, as oitivas realizadas em juízo permitem concluir que DIONATAN frequenta o imóvel, em conjunto com o próprio Reginaldo, de forma assídua, conforme apontado pela a informante Thamires, que reside no imóvel ao lado, pela testemunha Donizete e pela informante Isabel.

Assim, todos os demais elementos probatórios convergem no mesmo sentido, atestando a autoria delitiva.

Ademais, conforme se vê pelo laudo pericial de fls. 171/174, a arma de pressão, que teve seu calibre alterado para alojar cartuchos calibre 22, encontrando-se, inclusive, carregada com um cartucho CBC deflagrado, no estado em que se encontrava, poderia ser eficazmente utilizada para efetuar disparos, bem como os 2 (dois) cartuchos encontrados mostraram-se devidamente eficazes.

Constou, ainda, no referido laudo, que "(...) a semelhança formal com uma arma de fogo, a adaptação para calibre 22, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que a aludida arma de pressão pode ser perfeitamente confundida com arma de fogo verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação com seu potencial lesivo." (fls. 174).

Desta feita, ante a adaptação da arma de pressão para efetuar disparos de munição calibre 22, conforme o laudo pericial supracitado, e considerando que o calibre nominal 22 está inserido na categoria de arma de fogo de uso permitido, conforme disposto no artigo 3º, inciso I, do Decreto Federal n. 10.030/2019, e Portaria n. 1.222/2019 (Anexo A) do Ministério da Defesa, o caso se amolda ao delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

Ressalto que o laudo foi elaborado de maneira clara e discriminada por órgão especializado, sendo que nada há que o inquine descrédito.

Esclareço que os delitos previstos na supracitada lei são crimes de perigo abstrato, isto é, representam afronta à norma jurídica que visa, neste caso, garantir e preservar a segurança coletiva, conforme já decidiu o STF (HC 96.072) e o STJ (HC 156.736).

Assim, a situação de perigo é presumida, independentemente da intenção do agente, de forma que a consumação se dá com a mera posse da arma de fogo, sem o registro e o necessário porte, sendo irrelevante a sua efetiva utilização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de arma de uso permitido. Defesa alega, em preliminar, atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a consideração da atenuante da confissão na segunda etapa de dosimetria, diminuindo-

se as penas. Almeja, por fim, a restituição da arma apreendida e da fiança depositada. Sentença comporta parcial reforma. Preliminar rejeitada. Crime de perigo abstrato. Precedentes dos Tribunais Superiores. Ausência de comprovação do alegado prejuízo. No mérito, autoria e materialidade demonstradas. Réu foi preso em flagrante e admitiu a prática delitiva. Laudo pericial comprova a potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas. Condenação de rigor. Dosimetria comporta ligeiro reparo. Na segunda fase, necessário reconhecer a confissão. Penas inalteradas, pois resta impossível operar a redução a quem do mínimo legal nesta fase. Súmula 231 do STJ. Regime inicial aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Mantido efeito extrapenal da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, a, do Código Penal. Juízo a quo já determinou a restituição da fiança. Recurso parcialmente provido, sem alteração nas penas. (TJSP; Apelação Criminal 0004814-03.2017.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação do réu DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS pela infração ao delito do artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03 é medida que se impõe.

IV) Do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal):

Em relação ao réu DIONATAN, foram comprovadas a materialidade e autoria em relação aos delitos previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, sendo afastada apenas a imputação do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Assim sendo, por se tratarem de condutas distintas com resultados de igual modo diversos, forçoso reconhecer a presença do concurso material de crimes, razão pela qual as penas relativas a cada crime deverão ser somadas, nos termos do disposto pelo artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena do réu DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS, com base no critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

I) Artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06:

O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, observando-se o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que natureza e diversidade da droga apreendida (maconha e crack) possibilita o aumento da pena-base, tendo em vista o crack tratar-se de substância que se afigura como entorpecente de alta periculosidade, causadora de maior dependência ao usuário e maiores riscos ao meio social. Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social do réu. A culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal e inerente ao delito. Apesar dos registros criminais em seu nome, o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 348/352 e 353/356). Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado (coletividade), nada a analisar sobre comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga apreendida), elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 1/8 sobre 10 anos ou 120 meses), resultando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, eis que o acusado é reincidente específico (condenação anterior por tráfico - processo n. 1501418-

85.2019.8.26.0242, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/2020 - fls. 355), motivo pelo qual agravo a pena 1/3 (um terço), perfazendo o montante de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Inviável a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/06, já que o réu é reincidente específico, conforme delineado acima. Logo, deve a pena ser

mantida em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Desta forma, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

II) Artigo 14 da Lei n. 10.826/03:

O artigo 14, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tem como pena base o patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Logo, fixo a pena-base, no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, eis que o acusado é reincidente (condenação anterior por tráfico - processo n. 1501418-85.2019.8.26.0242, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/2020 - fls. 355), motivo pelo qual agravo a pena 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

III) Artigo 69 do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), as penas deverão ser somadas, resultando em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, "caput", ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. Diante da quantidade de pena e das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), bem como o fato de se tratar de tráfico de entorpecentes, delito com grande danosidade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (saúde pública) e ao meio social, acompanhada de porte de arma de fogo, reputo necessária, para a adequada repressão e prevenção do crime, a imposição de regime inicial fechado, principalmente para desestimular a reiteração de semelhante conduta pelo acusado (prevenção especial negativa), observando-se o teor do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

A quantidade da pena privativa de liberdade fixada impede a substituição por penas restritivas de direitos, bem assim a suspensão condicional da sua execução (artigos 44 e 77 do CP).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu DIONATAN MOREIRA DA FONSECA DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 e artigo 14, da Lei Federal n. 10.826/03, nos termos do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato;

B) ABSOLVER o réu ANTÔNIO MARCOS GOMES FILHO da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C) ABSOLVER os réus DIONATAN MOREIRA DA FONSECA e ANTÔNIO MARCOS GOMES FILHO da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu DIONATAN não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo ele respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença condenatória. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência,

não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008